

1500470-85.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... com a ocorrência do delito de tráfico na conduta do réu e sua autoria, posto que pugna apenas por fixação da pena com o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

E, se assim não fosse, a prova dos autos, de forma segura e convincente demonstra a ocorrência dos fatos como narrados na denúncia, a configuração do delito de tráfico de drogas; a autoria deles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500470-85.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500470-85.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

ANDERSON DOS SANTOS, qualificado à fls. 10, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

" Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de junho de 2022, por volta das 20h45min, na Rua Antônio Pereira Galindo, n.º 425, Conjunto Habitacional Ana Jacinta, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, ANDERSON DOS SANTOS, qualificado à fl. 10, mantinha em depósito 01 (um) invólucro plástico contendo 21,55 (vinte e um gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína; 13 (treze) invólucros plásticos contendo 18,13 (dezoito gramas e treze decigramas) de cocaína e 01 (um) invólucro plástico contendo 28,06 (vinte e oito gramas e seis centigramas), para fins de fornecimento a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotografias (fls. 21/24) e laudo pericial definitivo (fls. 112/114). Segundo apurado, o denunciado adquiriu de terceiro não identificado as porções de cocaína acima descritas, com o intuito de revender a droga nesta cidade. Na data do ocorrido, policiais militares receberam denúncia anônima de que

o denunciado estaria praticando o crime de tráfico de entorpecentes em sua residência. Diante disso, os policiais se dirigiram até o local. ANDERSON estava dentro do imóvel e acompanhou a vistoria na casa. Na cômoda de seu quarto foram encontrados uma porção bruta de cocaína com peso líquido aproximado de 21,55 (vinte e um gramas e cinquenta e cinco centigramas) e 12 (doze) papelotes da mesma droga com peso líquido aproximado de 18,13 (dezoito gramas e treze centigramas); além de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro em cédulas diversas; uma máquina de cartão de crédito; uma agenda com anotações da mercancia ilícita (fls. 127/135) e saquinhos plásticos para preparo da droga com vestígios de cocaína (fls. 115/117). Ato contínuo, os policiais solicitaram apoio do canil e, em uma geladeira no fundo do quintal da casa, localizaram outra porção bruta de cocaína. No andar superior foram encontrados vários eppendorfs dentro de um saco plástico, também utilizados no preparo da droga a ser comercializada. O laudo pericial de constatação comprovou a presença da substância cocaína constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e Portaria SPTC 136/20 na droga apreendida. Considerando a apreensão da quantidade de cocaína, sendo parte já embalada para a venda e a forma como as porções estavam divididas e armazenadas, não há dúvidas de que a substância entorpecente apreendida tinha como destino a mercancia ilícita." Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls.155/158), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 162), o despacho de fls. 163/168, de 23 de agosto de 2023, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Na instrução do feito ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e foi o réu regularmente interrogado.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 182/183) pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia, com a negativa da aplicação da figura do tráfico privilegiado, em razão da quantidade e da qualidade das drogas apreendidas. Por seu turno o nobre Dr. Defensor (fls. 182/183), pediu em preliminar no reconhecimento da ilicitude da prova, por ter havido violação do domicílio do réu na diligência polícia. No mérito, bateu-se apenas pela aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fixação da pena no mínimo e substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20; pelas fotos de fls. 21/25; pelo laudo pericial de fls. 112/114, que concluiu: "O exame do mesmo revelou: Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0036584 ) Descrição: 1 (um) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de material sólido particulado, de cor branca, e um fragmento de plástico. Massa Bruta e/ou Quantidade: 27,56 grama(s) - vinte e sete gramas e cinquenta e seis centigramas. Massa Líquida: 21,55 grama(s) - vinte e um gramas e cinquenta e cinco centigramas. Destes, uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0089769 quando das realizações do exame de constatação. Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0036583 ) Descrição: 13 (treze) invólucros plásticos, sendo 12 (doze) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip"), todos invólucros, encerrando porção de material sólido particulado, de cor branca. Massa Bruta e/ou Quantidade: 27,35 grama(s) - vinte e sete gramas e trinta e cinco Massa Líquida: 18,13 grama(s) - dezoito gramas e treze centigramas. Destes, uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância

COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0089769 quando das realizações do exame de constatação.”; pelo laudo pericial de fls. 115/117, que concluiu: “O exame do mesmo revelou: Item 1 (Acondicionado sob o lacre 019709 ) Descrição: 1 (um) invólucro plástico encerrando 123 embalagens plásticas com fechamento por pressão (tipo "zip") com massa total de 28.06 grama(s), cada unidade dotada de dimensões aproximadas de 5 cm de comprimento por 4 cm de largura, apresentando resquícios/sujidades. Massa Bruta e/ou Quantidade: 34,86 grama(s) - trinta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0089742. Item 2 (Acondicionado sob o lacre 019713 ) Descrição: 1 (um) invólucro plástico encerrando aproximadamente 1016 microtubo(s) plástico(s) do tipo "Eppendorf" dotado(s) de tampa própria, com massa total de 589.27 grama(s), cada unidade dotada de dimensões aproximadas de 2,5 cm de comprimento por 1.3 cm de diâmetro, sem resquícios/sujidades aparentes. Massa Bruta e/ou Quantidade: 634,07 grama(s) - seiscentos e trinta e quatro gramas e sete centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0089742. OBSERVAÇÃO: Os resquícios/sujidades da superfície do material foram removidos com uso de solventes adequados, sendo toda a amostra obtida utilizada nas análises do presente laudo. Face a sua exiguidade não foi possível armazenar amostra de contraperícia.”: pelo laudo pericial de fls. 118/126; pelo laudo pericial de fls. 127/135; além da prova oral carreada para os autos. Em preliminar o nobre Dr. Defensor arguiu a ilicitude da prova dos autos em razão ter ocorrido violação do domicílio do réu por parte dos policiais que adentraram na residência sem autorização do morador ou sem autorização judicial.

Não acolho a referida preliminar.

O tráfico de drogas é, delito permanente, e por este motivo é que se tem a consumação protraída no tempo despicienda prévia autorização judicial. Assim, e também porque a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, é de ser rechaçada a irresignação, pois, não tem lugar a criação de empecilhos à legítima atuação policial. Mister se tenha presente que inexiste liberdade pública absoluta. Ora, a própria vida é excepcionada pela Carta Magna extraordinariamente (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “a”, da Carta Política).

Nesse sentir, oportuno consignar que a traficância representa um atentado à saúde pública. Constitui, pois, a violação primeira à ordem jurídica, e que não pode, a título de uma pseudogarantia, passar despercebida. Estar-se-ia, do contrário, a vilipendiar o Princípio da Proporcionalidade, que ordena, por excelência, o choque entre direitos de igual hierarquia..

Note-se que o depoimento prestado por policial, nos autos. agente público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É, afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:

“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial, quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. nº 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro

julgado desta Augusta Corte ficou destacado que 'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida' (TJSP, Ap. Crim. nº 234.718-3, 3ª Câmara. Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (in RT 730/569)" - Apelação Criminal nº 0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).

E ainda:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE. LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3. Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06" (Apelação Criminal nº 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em 04.08.11, v.u.).

Ab initio, a preliminar alegação de falta de mandado de busca e apreensão, autorização do réu ou justa causa para a entrada dos policiais militares em sua residência não tem o condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas, diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e consequentemente, da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais, não se mostra possível alegar a referida garantia constitucional. Tratando-se de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, afastada fica a inviolabilidade de domicílio, em atenção à própria norma constitucional, que estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)", tem-se que caracterizada estava a situação flagrancial no momento da ação policial.

O tipo penal do tráfico, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, estabelece as condutas caracterizadoras do ilícito, quais sejam, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Assim, aquele que tem em depósito drogas na sua residência, com nítida finalidade mercantil, comete o crime de tráfico de drogas, estando em situação de flagrante delito, vez que a situação de flagrante delito possibilita o ingresso de agentes policiais no domicílio mesmo sem autorização do morador ou mandado judicial.

Tampouco é possível dizer que, no caso dos autos, não havia um justo motivo para os agentes policiais ingressarem na casa em que foram localizadas as drogas. Ressalta-se que deve existir um mínimo de visibilidade prévia acerca da existência de infração penal em andamento a justificar o ingresso domiciliar, sem o consentimento do morador e sem autorização judicial, contudo, essa justificativa pode e deve ser analisada dentro das circunstâncias do caso concreto.

Os policiais salientam que o réu franqueou o ingresso.

Se não fosse isso, não se constata qualquer irregularidade ou violação na busca realizada pelos policiais.

No caso dos autos, tais circunstâncias mostram-se suficientes para o afastamento de qualquer alegação de nulidade da prova.

Até porque havia fundadas e sérias razões para se perseguir o réu, diante das informações que possuíam acerca do tráfico de drogas no local, e por fim, encontram

uma grande quantidade de drogas com os réus, que da forma em que foram localizadas, evidenciam sobremaneira a traficância no local, graças à rápida e eficaz atuação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas.

Assim, não se exige prova cabal, indubitosa, da prática de delito, bastando que haja fundada suspeita. E, no caso dos autos, essa suspeita se fazia presente com a denúncia anônima, os policiais afirmaram que tinha informações que o réu comercializava drogas em um bar próximo ao endereço relatado como residência dele. A denúncia apontava ainda que ele estava foragido do sistema penitenciário.

Efetuada a abordagem nada de ilícito foi localizado, dirigiram ao endereço de Tiago e esse franqueou a entrada e acompanhou as buscas e localizaram a droga.

Deve-se salientar, ainda, que ao réu é constitucionalmente assegurado o direito de não produzir prova contra si próprio, sendo natural que o mesmo refute a prática do crime que lhe é atribuído. Contudo, a tese defensiva de negativa de autoria deve ser analisada em conjunto com as demais evidências do processo e, no presente caso, sopesando as versões do acusado e dos policiais, estas se sobressaem, sobretudo porque coerentes e alinhadas ao arcabouço probatório.

Ademais, os policiais rechaçaram qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que não se verifica, repito, qualquer motivo ou circunstância fática que justifiquem a falsa incriminação do réu por parte dos agentes públicos. Com efeito, a prova deve ser analisada em conjunto e não isoladamente. Os depoimentos dos policiais devem ser contrastados com os demais elementos existentes nos autos e não havendo razão aparente para desconfiar de eventual atividade irregular na ação seus relatos são válidos como prova.

Ressalta-se, que o objetivo maior da polícia deve ser a abordagem e detenção do indivíduo que está perpetrando o tráfico, buscando, inclusive, garantir a segurança dos agentes e também do suspeito.

Pouco plausível, ainda, que os policiais durante suas rotinas, mantenham estoque de drogas destinadas ao enxerto com o objetivo de imputar, falsamente, a terceiros, a prática de ilícitos penais.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. RECORRENTE ABORDADA EM VIA PÚBLICA, OCASIÃO EM QUE FOI ENCONTRA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS, ANTES DA ENTRADA DOS AGENTES EM DOMICÍLIO ALHEIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade, pela ausência de mandado de busca e apreensão, insta consignar que tanto a jurisprudência desta Corte, como a do Eg. Supremo Tribunal Federal, firmaram o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime permanente, como é o delito de tráfico de entorpecentes mostra-se prescindível o mandado judicial, em caso de flagrante, como na hipótese. III - No caso, sub examine, no qual se alega a ocorrência de irregularidade face a ausência de mandado judicial, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a atuação dos agentes policiais no sentido de ingressar em domicílio alheio teve como elementos precursor e a abordagem realizada em via pública, "[...]momento que encontraram pequena porção de substâncias entorpecentes", bem como informação acerca da existência de mais droga no local em que ela reside, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada.

Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. IV - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. V - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da ora agravante acarretaria

risco à ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva da ora Agravante, porquanto, consoante se deduz dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, tendo o magistrado primeiramente ressaltado na decisão objurgada que ela "já responde a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas (0007559-75.2018.805.0191), onde foi concedida liberdade cumulada com medidas cautelares diversas da prisão", circunstância que indica a periculosidade concreta da agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC140.998/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Segundo o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1281760AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020).

E na mais recentíssima decisão daquele C. Supremo Tribunal:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIOABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido" (RHC 213852 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO. D.j. 30/05/2022).

É que quando se trata de crime permanente, como o porte de arma e munição, não há a invasão preconizada, pois a flagrância protraí-se no tempo, podendo, a qualquer

momento, o policial prender o réu. Existe, ainda, exceção à necessidade de mandado de busca e apreensão. Não existe, pois, violação de preceito constitucional, art. 5º, XI, da Carta Magna, ou legal (art. 303 do Código de Processo Penal). A prisão foi feita em conformidade com os ditames legais. O direito em análise não é absoluto, quando há flagrância, pode-se agir, caso contrário, outro tipo de violação poderia ocorrer, até mais grave. "Este Tribunal Superior prega que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protraí no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5º, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio" (HC 208957/SP- 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) - J. 6.12.2011 - DJe 19.12.2011). Cf., ainda, HC 101628/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora convocado do TJ/MG) - J. 21.10.2008 - DJe 10.11.2008; HC77489/AM- 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - J. 12.2.2008 - DJe 17.3.2008; HC 40056/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Hamilton Carvalhido - J. 30.6.2005 - DJ 05.09.2005, p. 493; HC 32934/GO- 5ª do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Gilson Dipp - J. 28.4.2004 - DJ 14.6.2004, p. 258 e RHC 14946/SP - 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - J. 1.4.2004 - DJ 03.05.2004, p. 184 e REVFOR vol. 375, p. 406).

O C. Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: 'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori' (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Tal matéria, todavia, foi suscitada novamente e em reexame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça e no julgamento de Habeas Corpus nº 598.051 - SP (2020/0176244-9) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no dia 2/3/2021, decidiu: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. [...] 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente [...] (HC 598.051/SP. MATÉRIA CRIMINAL. Relator Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 6ª Turma. JULGADO: 02/03/2021. Publ. 15/03/2021).

O Min. Relator Rogério Cruz justificou a decisão da turma em que, somente fundadas razões e desconfiças dos agentes do estado, não são suficientes para o ingresso sem mandado judicial na casa do suspeito, e além disso, "deve haver documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado, seja toda registrada em áudio e vídeo, de maneira a não deixar dúvidas quanto a legalidade da ação estatal

e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado". Entretanto, tal matéria foi objeto de análise em sede de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e teve como Relator Min. Alexandre de Moraes, que decidiu de acordo com a repercussão geral daquela Corte quando descreve "o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, conseqüentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Também ponderou que a TESE é de que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

Sem mais aprofundamento sobre a matéria e esgotada toda e qualquer discussão acerca do tema, merece então trazermos a parte final do julgamento que ocorreu no dia 02/12/2021, pelo Ministro Alexandre de Moraes, conforme segue:

"Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa)[...]."

Portanto, sobre todos os ângulos de análise, mostra-se absolutamente descabida a tese de nulidade baseada na "Teoria dos frutos da árvore envenenada" e em suposta violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, afastando-se o pleito defensivo.

Por todo o exposto, é que não acolho a preliminar arguida pelo Defensor Público. Antes de passar a análise do mérito, anoto que a defesa não postulou em sede de alegações finais a absolvição do réu, requerendo após preliminar de ilicitude de prova teses relacionadas pura e simplesmente a dosagem da pen; e isto deixa assentado sua concordância com a ocorrência do delito de tráfico na conduta do réu e sua autoria, posto que pugna apenas por fixação da pena com o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

E, se assim não fosse, a prova dos autos, de forma segura e convincente demonstra a ocorrência dos fatos como narrados na denúncia, a configuração do delito de tráfico de drogas; a autoria deles pelo réu e a inexistência de qualquer causa de exclusão de ilicitude.

O PM. Carlos Miguel, narrou nos autos que em razão de denúncias que o réu estaria realizando o tráfico de drogas, foram para sua residência e lá na casa se fazia constaram que estavam presentes Anderson, sua esposa e mais quatro pessoas; estavam fazendo uso de narguilé e nada de ilícito foi encontrado com elas; Anderson franqueou a entrada na casa e acompanhou as buscas; foi localizado na cômoda do quarto uma pedra bruta de cocaína e doze papéletes da mesma droga; nesse momento Anderson confessou que estava realmente comercializando droga, e que vendia cada porção por cinquenta reais; Anderson inclusive disse que havia vendido duas porções da droga e que fazia dois meses que traficava droga; também localizaram no quarto a quantia de R\$ 120,00 em dinheiro; ali também encontraram uma máquina de cartão de crédito, uma agenda com anotações e, bem como mais saquinhos plásticos para colocar droga; com apoio do canil e o cão indicou numa geladeira que estava no fundo do quintal, na parte de baixo dela, mais droga e localizamos outra pedra bruta de cocaína; Anderson assumiu a propriedade das drogas; na parte superior da casa, um andar em construção, também foram localizados vários eppendorf dentro de um saco



plásticos, no entanto Anderson negou a propriedade.

O PM. Adriano Beto, narrou nos autos que denúncias anônimas davam conta que Anderson estaria traficando drogas em sua casa; foram até o local e, em conversa com Anderson, informamos a ele sobre o conteúdo das denúncias; na casa estava a sua esposa e mais quatro pessoas, que estavam fazendo uso de narguilé e nada de ilícito foi encontrado com elas; Anderson franqueou a entrada na casa e acompanhou as buscas; localizaram na cômoda do quarto dele uma pedra bruta de cocaína e doze papérolas da mesma droga, que Anderson confessou que estava realmente comercializando droga, que vendia cada porção por cinquenta reais; Anderson inclusive disse que havia vendido duas porções da droga e que fazia dois meses que traficava droga; também localizaram no quarto a quantia de R\$ 120,00 em dinheiro; ali também encontraram uma máquina de cartão de crédito, uma agenda com anotações e mais saquinhos plásticos para endeloção da droga; com apoio do canil e o cão indicou numa geladeira que estava no fundo do quintal, na parte de baixo dela, mais droga e localizaram outra pedra bruta de cocaína; Anderson assumiu a propriedade das drogas; na parte superior da casa, um andar em construção, também foram localizados vários eppendorf dentro de um saco plásticos, no entanto Anderson negou a propriedade;

Quando interrogado em juízo o réu confirmou a narrativa dos policiais, confessando a prática do delito de tráfico quando dos fatos da denúncia.

Afirmou naquela oportunidade: "no ano de 2007 fui preso por tráfico de drogas, mas depois absolvido; tenho dois filhos menores de idade; minha esposa está ciente da prisão; não fui agredido pelos policiais; não tenho advogado; como estava sem dinheiro para pagar água e luz, há uns quatro dias comprei 50 g de cocaína por R\$ 1.600,00 e já tinha vendido duas porções por cinquenta reais cada; nesta data, policiais militares foram até minha casa e disseram que meu filho Caio Felipe tinha sido preso com maconha e foram até minha casa verificar se havia mais drogas; falei para os policiais que dentro do meu quarto tinham alguns papérolas de cocaína, uma pedra bruta, dinheiro e uma máquina de cartão; essa máquina utilizo porque vendo bebidas e minha esposa vende roupas; também localizaram no quintal outra pedra bruta de cocaína; dentro do quarto também havia saquinhos plásticos; na parte superior há uma casa sendo construída, mas não tenho nada a ver com o que encontraram lá; somente aluguei a parte de baixo; nesta delegacia fiquei sabendo que meu filho Caio Felipe foi preso com maconha".

Como só podia acontecer, em juízo, negou a imputação, afirmando que houve efetivamente a apreensão e sua prisão, mas que não autorizou o ingresso dos policiais em sua casa e que a droga que foi encontrada se destinava ao seu uso pessoal.

Essa negativa do réu não encontra respaldo na prova dos autos e o conjunto probatório demonstra que os fatos se passaram como narrados na denúncia, ou seja, a ocorrência do delito de tráfico de drogas na conduta do réu.

No caso, estando a confissão informal em consonância com os demais elementos de convicção, consoante apontado, também ostenta valor probatório. Nesse sentido: A respeito da figura da confissão informal, reproduz-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: 'O detido poderá dar depoimentos aos policiais na sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu quando este foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos daqueles que a ouviram' (O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 230). A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a possibilidade da utilização da confissão informal como relevante elemento de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Índícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral

e Silva, j. Em 8/1/2009)." (em TJSP, Apelação n. 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016).

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil."(TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de corréu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

A palavra, uníssima, dos policiais que realizaram a diligência, a apreensão das drogas e a prisão do réu, é suficiente para alicerçar a condenação.

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))."

"Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. ((RJ TJSP 125/563))."

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pag. 12.189))."

A tudo isso se alia os elementos trazidos pelos laudos periciais que constaram os objetos apreendidos na casa do réu resquícios de drogas; o caderno apto a realizar anotação de tráfico e no celular diálogos indicam tráfico de drogas.

De rigor a procedência da ação penal e a condenação do réu Anderson pelo delito de tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Embora o réu tenha extensão certidão de antecedentes criminais, é ele tecnicamente primário. Não possui sentença condenatória e muito menos condenatória com trânsito em julgado, para possibilitar o reconhecimento da reincidência e até mesmo de maus antecedentes. Os procedimentos tiveram fim ou com absolvição; com arquivamento do procedimento administrativo ou com sentença de extinção de punibilidade antes de iniciar a ação penal.

Apreendeu-se a posse do réu quantidade que pode ser considerada considerável e em razão deste detalhe o Ministério Público se opõe ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, mas essa posição ministerial não pode ser acolhida.

No tocante à circunstância especificada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis idem bis.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu

meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. [...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas

primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]"(Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases." "[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, para caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181). "[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse